Aktenzeichen:
7 O 31/16

Landgericht Mannheim

Im Namen des Volkes

Urteil

In dem Rechtsstreit

(...)
- Klägerin -

Prozessbevollmächtigte:
(...)

gegen

(...)
- Beklagte -

Prozessbevollmächtigte:
(...)

wegen Patentverletzung

hat das Landgericht Mannheim - 7. Zivilkammer - durch den Vorsitzenden Richter am Landgericht (...), den Richter am Landgericht (...) und den Richter am Landgericht (...) auf Grund der mündlichen Verhandlung vom 21.10.2016 für Recht erkannt:

I. Die Beklagte wird verurteilt,
der Klägerin in einer gesonderten Aufstellung hinsichtlich der Angaben zu a. und b. unter Vorlage von Rechnungen oder Lieferscheinen oder Quittungen, darüber Angaben zu machen, in welchem Umfang sie Funkstationen

in der Bundesrepublik Deutschland angeboten, in den Verkehr gebracht oder gebraucht oder zu den genannten Zwecken eingeführt oder besessen hat,

wenn die Funkstationen jeweils Folgendes umfassen:

Sendemittel, um über einen Kanal innerhalb einer vorgegebenen Zeitspanne einen Datenblock zu übertragen, der Informationssymbole und Paritätsprüfungssymbole enthält;

Steuermittel, die auf eine Angabe bezüglich einer Reduzierung der Kanalqualität gemäß einem ersten Kriterium mit einer Verringerung der Datensendeleistung reagieren und

die auf eine Angabe innerhalb der vorgegebenen Zeitspanne bezüglich der Zunahme der Kanalqualität entsprechend einem zweiten Kriterium mit einer Erhöhung der Datensendeleistung reagieren,

und zwar unter Angabe

a. der Menge der erhaltenen oder bestellten Erzeugnisse, sowie der Namen und Anschriften der Hersteller, Lieferanten und anderer Vorbesitzer,

b. der einzelnen Lieferungen, aufgeschlüsselt nach Liefermengen, -zeiten und -preisen, den jeweiligen Typenbezeichnungen sowie den Namen und Anschriften der Abnehmer,

c. der einzelnen Angebote, aufgeschlüsselt nach Angebotsmengen, -zeiten und -preisen, der jeweiligen Typenbezeichnungen sowie der Namen und Anschriften der Angebotsempfänger,

d. der betriebenen Werbung, aufgeschlüsselt nach Werbeträgern, deren Auflagenhöhe, Verbreitungszeitraum und Verbreitungsgebiet, im Falle von Internet-Werbung der Domain, den Zugriffszahlen und den Schaltungszeiträumen,

e. der nach den einzelnen Kostenfaktoren aufgeschlüsselten Gestehungskosten und des erzielten Gewinns,

wobei der Beklagten vorbehalten bleibt, die Namen und Anschriften der nichtgewerblichen Abnehmer und Angebotsempfänger statt der Klägerin einem von ihr zu bezeichnenden, ihr gegenüber zur Verschwiegenheit verpflichteten vereidigten Wirtschaftsprüfer mitzuteilen, sofern die Beklagte dessen Kosten trägt und ihn ermächtigt und verpflichtet, der Klägerin auf konkrete Anfrage mitzuteilen, ob ein bestimmter Abnehmer oder Angebotsempfänger in der Aufstellung enthalten ist.

II. Es wird festgestellt, dass die Beklagte verpflichtet ist, der Klägerin allen Schaden zu ersetzen, der ihr durch die in Ziffer I, bezeichneten Handlungen entstanden ist und noch entstehen wird.

III. Im Übrigen wird die Klage abgewiesen.

IV. Von den Kosten des Rechtsstreits tragen die Klägerin 2/3, die Beklagte 1/3.

V. Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar gegen Sicherheitsleistung in Höhe von € 50.000 in Ziffer I. und im Übrigen gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 120% des jeweils zu vollstreckenden Betrages (Ziffer IV. Kosten).

Tatbestand

Die Klägerin nimmt die Beklagte wegen behaupteter Verletzung des Patents EP 1 623 511 B1 auf Unterlassung, Auskunft/Rechnungslegung, Vernichtung und Rückruf/Entfernung aus den Vertriebswegen in Anspruch und begehrt die Feststellung einer Schadensersatzpflicht.

Die Klägerin ist ein weltweit operierendes Elektronikunternehmen, das u.a. auf dem Gebiet der Mobilfunktechnologie zahlreiche Patente hält. Die Beklagte ist die deutsche Tochtergesellschaft des taiwanesischen Unternehmens A. Sie vertreibt in der Bundesrepublik Deutschland UMTS- und LTE-fähige Mobiltelefone und Tablets, die das HSUPA-Schema anwenden können, unter der Marke „A" (angegriffene Ausführungsformen).

Die Klägerin ist Inhaberin des Europäischen Patents EP 1 623 511 B1, das sich auf Funkstationen zur Verwendung in einem drahtlosen Kommunikationssystem bezieht (Klagepatent). Das Klagepatent ist auch mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteilt und steht in Kraft. Es beansprucht die Priorität der britischen Anmeldung 0310289 vom 3. Mai 2003, die Veröffentlichung der Patenterteilung erfolgte am 7. März 2007. Der unabhängige Anspruch 1 des Klagepatents hat – in der Verfahrenssprache – folgenden Wortlaut (mit Bezugsziffern):

> A radio station (100) comprising transmitter means (110) for transmitting over a channel in a predetermined time period (0 to t_F) a data block comprising information symbols (*I*) and parity check symbols (*C*) and control means (150) responsive to an indication of a reduction in channel quality according to a first criterion for decreasing the data transmit power and responsive to an indication within the predetermined time period of an increase in channel quality according to a second criterion for increasing the data transmit power.

Wegen des weiteren Inhalts des Klagepatents, insbesondere wegen der Beschreibung und der zugehörigen Figuren, wird auf die Patentschrift Bezug genommen.

Gegen das Klagepatent hat die B Nichtigkeitsklage vor dem Bundespatentgericht eingereicht.

Das UMTS-Netz, in dem auch die Mobiltelefone der Beklagten arbeiten können, beruht seit dem Release 6, durch den das HSUPA-Schema – einer Ausbaustufe des UMTS-Standards – eingeführt wurde, u.a. auf folgenden verpflichtend einzuhaltenden Standards:

- ETSI TS 23 002 v6.10.0 (2005-12), Anlage K C2,
- ETSI TS 25 211 v6.10.0 (2009-09), Anlage K C3,
- ETSI TS 25.212 v6.10.0 (2006-12), Anlage K C4
- ETSI TS 25.213 v6.5.0 (2006-3), Anlage K C5
- ETSI TS 25.214 v6.11.0 (2006-12), Anlage K C6
- ETSI TS 25.427 v6.8.0 (2006-12), Anlage K C7.

Gemäß der Figur 1 des Standard-Dokuments nach Anlage K C5 werden Anwenderdaten von einer Transportebene, wo sie codiert werden, an die physikalische Kanäle DPCCH, DPDCH, HS-DPCCH, E-DPCCH und E-DPDCH) weitergegeben und entsprechend codiert. Diese Kanäle bilden einen Datenstrom, der mit „S" gekennzeichnet ist.

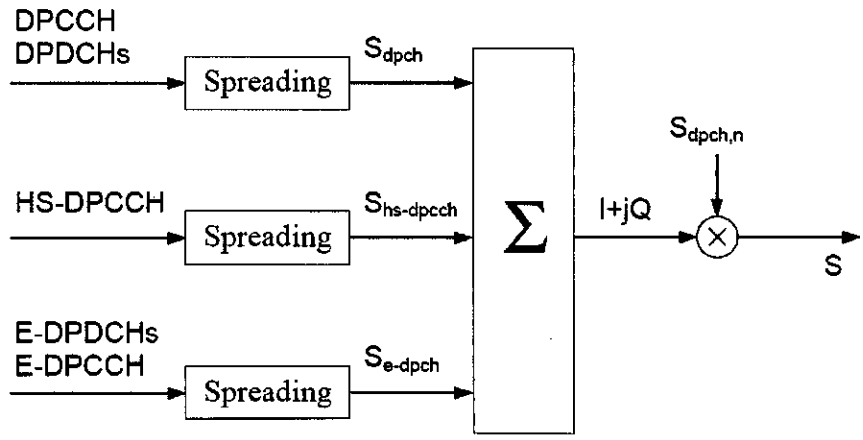

Figure 1: Spreading for uplink dedicated channels

Der physikalische Kanal E-DPDCH überträgt dabei Anwenderdaten wie Fotos und Videos und CRC-Daten (vgl. Anlage K C4).

Wenn die Kanalqualität abnimmt, wird die Datensendeleistung auf dem E-DPDCH-Kanal verringert. Die Regelung der Sendeleistung vollzieht sich dergestalt, dass die Mobilstation von der Basisstation gesendete TPC-Befehle empfängt. Anhand des TPC-Wertes errechnet die Mobilfunkstation, wie die Übertragungsleistung auf dem Kanal DPCCH anzupassen ist. Der TPC-Befehl hat dabei zunächst unmittelbar nur Auswirkungen auf den Kanal DPCCH. Über sogenannte „gain factors" wird dann auch die Sendeleistung des E-DPDCH geregelt. Die Version 6 des UMTS-Standards skaliert damit die Sendeleistung des E-DPDCH-Kanals, falls die Gesamtsendeleistung bei Befolgen des Befehls das maximal zulässige Maß überschreiten würde (Anlage K C6, Abschnitt 5.1.2.6, Seite 26, zweiter Absatz):

> When E-DCH is configured, if the total UE transmit power (after applying DPCCH power adjustments and gain factors) would exceed the maximum allowed value, the UE shall firstly reduce all the E-DPDCH gain factors $\beta_{ed,k}$ by an equal scaling factor to respective values $\beta_{ed,k,reduced}$ so that the total transmit power would be equal to the maximum allowed power. After calculating the reduced E-DPDCH gain factors, quantization according to table 1B.2 in [3] subclause 4.2.1.3 may be applied, where each $\beta_{ed,k,reduced}$ is quantized such that $\beta_{ed,k}/\beta_c$ is the largest quantised value for which the condition $\beta_{ed,k} \leq \beta_{ed,k,reduced}$ holds.

In entsprechender Weise vollzieht sich die Erhöhung der Datensendeleistung auf dem E-DPDCH-Kanal (vgl. auch ebenda siebter Absatz):

> Any scaling, and any reduction in the E-DPDCH gain factor as described above, shall only be applied or changed at a DPCCH slot boundary. In order that the total UE transmit power does not exceed the maximum allowed value the scaling or E-DPDCH gain factor reduction shall be computed using the maximum HS-DPCCH power transmitted in the next DPCCH slot. In the case that either an ACK or a NACK transmission will start during the next DPCCH slot, the maximum HS-DPCCH power shall be computed using one of the following:
>
> (a) whichever of Δ_{ACK} and Δ_{NACK} will be used according to whether the transmission will be ACK or NACK, *or*
>
> (b) whichever of Δ_{ACK} and Δ_{NACK} is the largest.

Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten der sich vollziehenden Abläufe wird auf die zitierten Standarddokumente verwiesen.

Die Klägerin hat mit der Firma C eine vertragliche Abrede geschlossen. Die Vertragsparteien haben in Klausel 17 Folgendes bestimmt:

> „This agreement shall be governed by and construed and enforced in accordance with the laws of the State of California without regard to conflict of laws principles.[...]."

In Klausel 4.3 findet sich folgende Bestimmung:

> „C Option to Obtain Covenant Not to Assert. D hereby grants C an option to designate any or all of its existing and future CDMA licensees as a „CDMA Technically Necessary Patent Beneficiary." C may exercise its option at any time and from time to time throughout the term of this Agreement, each time by sending written notice to D identifying each new CDMA Technically Necessary Pa-

tent Beneficiary. D, on behalf of itself and its Affiliates, hereby covenants that, as to each CDMA Technically Necessary Patent Beneficiary, D and its Affiliates will not assert any of their CDMA Technically Necessary Patents against any manufacture, use, sale, importation of equipment and/or components, or other acts of infringement, relating to a CDMA Wireless Industry Standard of a CDMA Technically Necessary Patent Beneficiary; provided however, that D and its Affiliates may assert their CDMA Technically Necessary Patents against any CDMA Technically Necessary Patent Beneficiary that asserts any of its patents against D or its Affiliates [...] or that initiates a declaratory judgement action, reexamination proceedings or opposition proceedings challenging the validity of any of Philips` CDMA Technically Necessary Patents; [...]."

A verbaut in den angegriffenen Ausführungsformen nicht nur C-Chips, sondern auch Chips anderer Hersteller.

Die Klägerin wies die Muttergesellschaft der Beklagten am 13. Dezember 2005 erstmals auf die Verletzung diverser Patente durch den Vertrieb von UMTS- bzw. LTE-fähigen Mobilstationen hin. Im Juni 2009 übermittelte die Klägerin an A eine Liste mit Patenten, die nach ihrer Auffassung für den UMTS-Standard essentiell sind, darunter auch das Klagepatent. Zwischen Juli 2009 und Juni 2015 trafen sich Vertreter der Klägerin und Vertreter von A fünfzehnmal und verhandelten über das Lizenzprogramm der Klägerin. Dabei bot die Klägerin eine Lizenz für USD (...) (pro verkaufter Einheit für den „*past use*") an. Die Klägerin erläuterte diese Gebühr unter Verweis auf eine nicht offen gelegte „Analyse eines Hauptakteurs der Telekommunikations-Branche", der den Anteil der Klägerin am UMTS-Portfolio mit (...)% angesetzt und damit eine Lizenzgebühr von (...)% des Endabgabepreises pro Einheit angeboten habe. Zudem verwies die Klägerin auf ein gleichfalls nicht zugänglich gemachtes Gutachten eines von E hinzugezogenen Experten und verglich ihr Portfolio mit dem von F und deren Lizenzforderungen. A bot der Klägerin im Gegenzug Lizenznahme an von ihrer Seite als für den UMTS-/LTE-Standard essentiell gehaltenen Patenten an, worauf die Klägerin nicht einging. Mit Email vom 17. September 2015 übersandte die Klägerin einen Lizenzvertragsentwurf an A gemeinsam mit einer aktualisierten Übersicht über ihr UMTS-/LTE-Patentportfolio nebst Claim-charts. A ist der Auffassung, dass eine Lizenzgebühr in Höhe von USD (...) pro Einheit für die Lizenzierung des UMTS-Portfolios angemessen sei. Nach letztmaliger Aufforderung durch Email vom 30. November 2015, ein angemessenes Gegenangebot vorzulegen, übersandte A der Klägerin ein „Term Sheet", das die Bereitschaft enthielt, USD (...) pro Einheit für die Lizenzierung des UMTS-Portfolios und USD (...) für die Lizenzierung des LTE-Portfolios nebst pauschal USD (...) für jegliche Nutzung in der Vergangenheit zu bezahlen und u.a. die Verpflichtung zur Lizenzzahlung auf den Vertrieb in den Ländern USA, Japan, Korea, China, Deutschland, England, Frankreich und Italien und solche Geräte beschränkte, die nicht mit C-Chips ausgestattet sind. Die Beklagte hat – nach

Klageerhebung eine Sicherheitsleistung in Höhe von € (...) durch notarielle Hinterlegung erbracht.

Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten der Lizenzvertragsverhandlungen wird auf die gewechselten Schriftsätze nebst Anlagen verwiesen.

Die Klägerin trägt vor,

die angegriffenen Ausführungsformen verletzten das Klagepatent unmittelbar wortsinngemäß.

Merkmal b sei verwirklicht. Das Klagepatent erhelle, dass die Paritätsprüfungssymbole dazu dienten, fehlerhaft übertragene Daten jedenfalls zu einem gewissen Grad rekonstruieren zu können. Genau dies ermöglichten die nach dem Standard vorgesehenen CRC-Bits auf dem E-DCH-Kanal, die der Fehlerprüfung dienten. Dass dann dieser Fehler auch korrigiert werde, lese der Fachmann als Selbstverständlichkeit mit.

Auch Merkmal c sei erfüllt. Es reiche aus, dass die angegriffenen Ausführungsformen auf Anforderung in der Lage seien, gemäß dem HSUPA-Standard zu arbeiten und dass sie entsprechende Steuermittel enthielten. Zudem sei ausreichend, dass der TPC-Befehl sich jedenfalls auf die Kanäle DPDCH/DPCCH beziehe. Insoweit sei genügend, dass bei Überschreitung eines gewissen Maximalwertes der Sendeleitung nach Anpassung der DPCCH-Leistung und Anwendung von Skalenfaktoren die Sendeleistung des E-DPDCH-Kanals über eine Verringerung des Stellfaktors für diesen Kanal reduziert werde.

Aus diesen Gründen werde auch Merkmal d verwirklicht.

Auf den covenant not to assert, der in dem Vertrag mit der Firma C vereinbart worden sei, könne sich die Beklagte nicht berufen, da dieser keine HSPA-/HSUPA-Mobiltelefone und ungeachtet dessen allenfalls die Chips von C erfasse. Entsprechend habe auch der englische High Court entschieden.

Schließlich greife der von der Beklagten erhobene kartellrechtliche Einwand nicht durch, da sie die Beklagte insbesondere vor Klageerhebung in ausreichender Weise über die Art und Weise der Berechnung der Lizenzgebühr ihres FRAND-Angebots informiert und damit alle Obliegenheiten, die der Europäische Gerichtshof in der Entscheidung Huawei ./. ZTE formuliert habe, bereits vor Klageerhebung erfüllt habe. Hierfür genüge die Mitteilung der verlangten Lizenzgebühr je Einheit, die auch ausreichend erläutert worden sei. Zu näheren Erläute-

rungen sei sie gegenüber der im Grundsatz lizenzunwilligen Beklagten ohnedies nicht verpflichtet gewesen. Zudem fehle es auch an einer marktbeherrschenden Stellung der Klägerin, da ihr eine solche durch das Klagepatent nicht verliehen würde, da die in Rede stehenden Funktionen für die Vermarktung nicht unerlässlich seien.

Die Klägerin **b e a n t r a g t**:

I. Die Beklagte wird verurteilt,

1. es bei Meidung eines für jeden Fall der Zuwiderhandlung vom Gericht festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zu EUR 250.000 – ersatzweise Ordnungshaft – oder Ordnungshaft bis zu sechs Monaten, im Falle wiederholter Zuwiderhandlungen bis zu insgesamt zwei Jahren, wobei die Ordnungshaft an ihrem jeweiligen Geschäftsführer zu vollstrecken ist, zu unterlassen

   Funkstationen

   in der Bundesrepublik Deutschland anzubieten, in Verkehr zu bringen oder zu gebrauchen oder zu den genannten Zwecken einzuführen oder zu besitzen, wenn die Funkstationen jeweils Folgendes umfassen:

   Sendemittel, um über einen Kanal innerhalb einer vorgegebenen Zeitspanne einen Datenblock zu übertragen, der Informationssymbole und Paritätsprüfungssymbole enthält;

   Steuermittel, die auf eine Angabe bezüglich einer Reduzierung der Kanalqualität gemäß einem ersten Kriterium mit einer Verringerung der Datensendeleistung reagieren und

   die auf eine Angabe innerhalb der vorgegebenen Zeitspanne bezüglich der Zunahme der Kanalqualität entsprechend einem zweiten Kriterium mit einer Erhöhung der Datensendeleistung reagieren.

2. Auskunft/Rechnungslegung wie tenoriert,

II. Schadensersatzfeststellung, wie tenoriert

III. Die Beklagte wird verurteilt,

1. die vorstehend unter Ziffer I.1. bezeichneten, im Besitz Dritter befindlichen Erzeugnisse aus den Vertriebswegen zurückzurufen, indem diejenigen Dritten, denen durch die Beklagte oder mit deren Zustimmung Besitz an den Erzeugnissen eingeräumt wurde, unter Hinweis darauf, dass die Kammer mit dem

hiesigen Urteil auf eine Verletzung des Klagepatents DE 60 2004 005 179 (deutscher Teil des EP 1 623 511 B1) erkannt hat, ernsthaft aufgefordert werden, die Erzeugnisse an die Beklagte zurückzugeben und den Dritten für den Fall der Rückgabe der Erzeugnisse eine Rückzahlung des gegebenenfalls bereits gezahlten Kaufpreises sowie die Übernahme der Kosten der Rückgabe zugesagt wird, und endgültig zu entfernen, indem die Beklagte diese Erzeugnisse wieder an sich nimmt oder die Vernichtung derselben beim jeweiligen Besitzer veranlasst,

2. die in ihrem unmittelbaren oder mittelbaren Besitz und/oder Eigentum befindlichen, vorstehend zu Ziffer 1. bezeichneten Erzeugnisse auf eigene Kosten zu vernichten oder nach ihrer Wahl an einen von ihr zu benennenden Treuhänder zum Zwecke der Vernichtung auf ihre — der Beklagten — Kosten herauszugeben (alternativ an einen zur Vernichtung bereiten Gerichtsvollzieher).

Die Beklagte **b e a n t r a g t**,

die Klage abzuweisen;

hilfsweise:

den Rechtsstreit bis zur Entscheidung des Bundespatentgerichts in dem von der B gegen das Klagepatent angestrengten Nichtigkeitsverfahren auszusetzen;

den Rechtsstreit bis zum Abschluss des Berufungsverfahrens über den Counterclaim der A und der I im Vereinigten Königreich über die Zulässigkeit der Klage wegen Verletzung des britischen Teils des Europäischen Patents EP 1 623 511 B1 gegen die Unternehmensgruppe der Beklagten auszusetzen.

Die Beklagte trägt vor,

die Klägerin benenne keine konkret angegriffenen Ausführungsformen. Ein pauschaler Verweis auf Standardspezifikationen des HSUPA-Standards sei wegen dessen Optionalität nicht ausreichend.

Die im Standard TS 125.212 (Anlage K C4) erwähnten CRC-Daten seien keine Paritätsprüfungssymbole im Sinne des Klagepatents nach Merkmal b, da der Standard eine zyklische Redundanzprüfung vorsehe und nicht die klagepatentgemäße Paritätsprüfung.

Ferner sei Merkmal c nicht verwirklicht. Denn der TPC-Befehl, den das Mobiltelefon nach dem Standard von der Basisstation empfange, enthalte keine Angabe über die Kanalqualität. Soweit die Klägerin sich auf Abschnitt 5.1.2.2.1 der Anlage K C6 beziehe, werde dort das Wort „should" verwendet, sodass die Erstellung eines TPC-Befehls anhand des Signal-Rausch-Verhältnisses nicht verpflichtend sei. Sonst hätte der Standard dies dem üblichen Sprachgebrauch des Standards für zwingende Vorgaben folgend mit „shall" gekennzeichnet. Zudem sei unklar, ob der TPC-Befehl überhaupt anhand eines auf eine etwaige Kanalqualität bezogenen Kriteriums erstelle, da dies in der Sphäre des Netzbetreibers gesteuert werde und sich mithin der Kenntnis der Beklagten entziehe.

Überdies könne der von dem Mobiltelefon verwendete TPC-Befehl keine aussagekräftige Aussage zur Kanalqualität des zur Übersendung des Datenblocks verwendeten Kanals enthalten, selbst wenn für die Erstellung des Signal-Rausch-Verhältnis verwendet worden sein sollte. Denn der standardgemäße TPC-Befehl beziehe sich nicht auf den Gesamtkanal S, den die Klägerin zur Darlegung des Verletzungssachverhalts bemühe, sondern nur auf die Kanäle DPCCH/DPDCH, die ein Teil dieses Gesamtkanals S seien.

Schließlich werde Merkmal c auch deshalb nicht verwirklicht, weil sich die Gesamtsendeleistung aller Uplinkkanäle nicht in Reaktion auf eine Reduzierung der Kanalqualität verringere. Nur dann werde aber das klagepatentgemäße Ziel der Effizienzsteigerung erreicht.

Merkmal d werde aus den nämlichen wie den zu Merkmal c angeführten Gründen nicht verwirklicht.

Die Anträge zur Auskunftserteilung und Rechnungslegung seien zu unbestimmt, die fehlende Schwärzungsbefugnis geheimhaltungsbedürftiger Daten unverhältnismäßig. Aufgrund der FRAND-Vorgaben seien keine Angaben zu den Gestehungskosten und zum erzielten Gewinn zu verlangen und ihr stehe nur ein Anspruch zur Schadensersatzberechnung im Wege der Lizenzanalogie zu. Da die Klägerin in ihrem Lizenzangebot nur eine Stücklizenz anbiete, seien auch keine Angaben zu erzielten Umsätzen geschuldet.

Die Beklagte könne sich auf eine der Firma C erteilte Lizenz berufen, die auch die hier interessierende Technologie mit dem Klagepatent umfasse. Insoweit seien die angeblichen Rechte der Klägerin zum einen erschöpft, zum anderen könne sich die Beklagte auf einen in dem Lizenzvertrag mit C enthaltenen *Covenant-not-to-assert* berufen, der sich nicht nur auf

C-Chips beziehe und Abnehmer solcher Chips, sondern auch andere Chiphersteller erfasse, sofern C diese gleichsam mit unter den durch den *Covenant-not-to-assert* gespannten Schutzschirm durch entsprechende Benennung einbezogen habe. Dies sei vorliegend der Fall, sodass die Klägerin auch dann nicht gegen die Beklagte vorgehen könne, wenn in den angegriffenen Ausführungsformen keine C-Chips verbaut seien. Die Klage sei vielmehr unzulässig.

Im Übrigen stehe der Durchsetzung der Unterlassungs-, Rückruf- und Vernichtungsansprüche der kartellrechtliche Zwangslizenzeinwand entgegen. Die Klägerin habe insbesondere vor Klageerhebung trotz Aufforderung nie erläutert, weshalb die von ihr geforderte Stücklizenz FRAND-Bedingungen entspreche. Ferner könne Schadensersatz nur im Wege der Lizenzanalogie entsprechend einem Satz gefordert werden, der seinerseits FRAND-Kriterien entspreche. Anspruch auf Verletzergewinn oder entgangenen Gewinn bestehe nicht. Daher seien auch die entsprechenden Auskünfte nicht zu erteilen.

Zudem werde sich das Klagepatent nicht gegenüber dem Nichtigkeitsangriff der B behaupten können. An näherem Vortrag zum fehlenden Rechtsbestand sehe man sich aufgrund der Vereinbarung zwischen der Klägerin und C gehindert.

Schließlich seien die Ansprüche teils verjährt, weil die Klägerin seit 13. Dezember 2005 Kenntnis von den vermeintlichen Verletzungshandlungen der Muttergesellschaft der Beklagten habe.

Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten des Vortrags der Parteien wird auf die gewechselten Schriftsätze nebst Anlagen Bezug genommen.

Entscheidungsgründe

Die Klage ist zulässig, aber nur in Teilen begründet.

Die Beklagte kann aus dem Vertrag zwischen der Klägerin und der Firma C keine Einwendungen gegen die gerichtliche Geltendmachung des Klagepatents ableiten.

Da die angegriffenen Ausführungsformen von der Lehre des geltend gemachten Hauptanspruchs 1 unmittelbar wortsinngemäßen Gebrauch machen, war die Beklagte zur Auskunft und Rechnungslegung zu verurteilen und ihre Schadensersatzverpflichtung festzustellen. Diese Ansprüche unterliegen auch nicht aus kartellrechtlichen Gründen Einschränkungen. Die auf Unterlassung, Rückruf/Entfernung aus den Vertriebswegen sowie Vernichtung gerichteten Anträge waren hingegen abzuweisen, da die Klägerin an der Durchsetzung der Ansprüche aus kartellrechtlichen Gründen gehindert ist.

Eine Aussetzung des Rechtsstreits mit Blick auf die von der B erhobene Nichtigkeitsklage war nicht angezeigt.

I.

Entgegen der Auffassung der Beklagten ist die Klägerin nicht aufgrund des in dem Vertrag zwischen der Klägerin und der Firma C enthaltenen „*Covenant Not to Assert*" gehindert, das Klagepatent gegen die Beklagte gerichtlich geltend zu machen.

1. Es kann dabei vorliegend offen bleiben, ob dieser Einwand bereits zur Unzulässigkeit der Klage führen würde (so die bisherige Kammerrechtsprechung GRUR-RR 2011, 49) oder lediglich dazu, dass sie unbegründet wäre. Dies würde von der Qualifikation der Abrede entweder als ein die Zulässigkeit der Klageerhebung betreffenden Prozessvertrag oder als eine die Begründetheit betreffende Lizenzabrede materiellen Rechts abhängen. Ob ein *Covenant-not-to-Assert* als das eine oder das andere einzuordnen ist, ist in den Einzelheiten umstritten (vgl. Hauck ZGE 2013, 201 ff.) und ist auf der Grundlage des jeweiligen Einzelfalls zu entscheiden (insoweit wohl auch LG München I Az.: 7 O 28263/13, GRUR-RS 2015, 04007, freilich die abzulehnende Lehre von der „negativen Lizenz" aufgreifend). Bevor indes die Entscheidung, ob im vorliegenden Fall das eine oder das andere vorliegt, getroffen werden kann, ist zu beurteilen, nach welchem anwendbaren Recht diese Frage zu beurteilen ist. Die Parteien haben vorliegend jedenfalls

mit Blick auf den Hauptvertrag das kalifornische Recht als anwendbares Recht vereinbart. Daraus folgt freilich nicht zwingend, dass dieses Recht auch auf die möglicherweise als gesonderte Vereinbarung, die lediglich in der nämlichen Vertragsurkunde enthalten ist, zu beurteilende Abrede des *Covenants-Not-to-Assert* anzuwenden ist. Sollte darin eine Abrede mit Bezug zum Prozessrecht zu erblicken sein, was das Ergebnis einer Auslegung der Klausel sein könnte, so könnte diese Frage, ähnlich wie es für Gerichtsstandsvereinbarungen insbesondere unter Verweis auf Art. 25 Brüssel Ia-VO, dessen Anwendbarkeit auf einen *Covenant-Not-to-Assert* – im Sinne einer Generalderogation verstanden – bislang soweit ersichtlich nicht diskutiert wird, aber auch offen bleiben kann, vertreten wird, nämlich nach der *lex fori* und damit vorliegend nach deutschem Recht zu beurteilen sein (so für Gerichtsstandsvereinbarungen etwa Schack, IZVR 6. Aufl. 2014 Rn. 518 ff.; Antomo ZZPInt 17 (2012), 183, 193 ff.). Andererseits kommt in Betracht, vorliegend auch den *Covenant-Not-to-Assert* der Rechtswahlklausel des Hauptvertrages und dem so gewählten Vertragsstatut zu unterstellen und damit zur Anwendung kalifornischen Rechts zu gelangen, das den *Covenant-Not-to-Assert* nicht prozessual versteht, sondern als eine nach US-amerikanischer Vorstellung zur Erschöpfung führende einfache Lizenz (vgl. hierzu Hauck a.a.O mit Nachweisen aus der Rechtsprechung).

2. Vorliegend führt jedoch sowohl eine Anwendung kalifornischen Rechts als auch eine Anwendung deutschen Rechts zu dem Ergebnis, dass sich die Abrede zwischen der Klägerin und C nicht auf solche Chips erstreckt, die von dritten Herstellern an die Beklagte geliefert wurden.

   a) Für die Interpretation der Beklagten, die Klausel erfasse auch Geräte mit Chipsätzen anderer Unternehmen, lassen sich bei Auslegung nach den Maßstäben des deutschen Rechts und mithin der *lex fori* weder im Wortlaut Anhaltspunkte finden, noch ist diese Interpretation das Ergebnis einer teleologischen, systematischen und historischen Auslegung der Bestimmung.

      Dem Wortlaut nach erstreckt sich die Vereinbarung in Ziffer 4.3 allein auf die Lizenznehmer von C („*any or all of its existing and future L licensees*"). Diese können als Begünstigte („*beneficiaries*") benannt werden. Entsprechend werden systematisch von der Regelung die derzeitigen oder künftigen Lizenznehmer von C in den Blick genommen. Auch vor dem Hintergrund von Sinn und Zweck des Vertrages erscheint es allein sinnvoll, dass C seine Kundschaft vor einer gerichtlichen Inanspruchnahme durch die Klägerin schützen will. Dagegen ist kein Interesse von C ersichtlich, die Kundschaft auch für den Fall von einer gerichtlichen Inanspruch-

nahme durch die Klägerin freizustellen, dass diese Kundschaft Produkte von Konkurrenten von C bezieht. Auch der Hinweis der Beklagten darauf, dass C auch für den Fall des Verbaus von fremden Chipsätzen Lizenzgebühren für die Auslizenzierung seines Patentportfolios beziehe, kann nicht überzeugen. Eine solche mit dem Vertrag verfolgte Intention wie die von der Beklagten vorgetragene wäre außergewöhnlich und müsste daher in den vertraglichen Vereinbarungen oder in den sie begleitenden Dokumenten Widerhall gefunden haben, da sich die Klägerin damit in unüberschaubarem, weil allein von C zu bestimmenden Ausmaß der Möglichkeit begeben hätte, gegen Drittanbieter, die keine Lizenz haben, gerichtlich vorzugehen. Die Beklagte kann insoweit nicht mit ihrer Argumentation überzeugen, diese Intention ergebe sich aus der Art und Weise wie die Begünstigten in der Vertragspraxis, wie sie zwischen der Klägerin und C gelebt worden sei, benannt worden seien. Denn zunächst hat sich eine entsprechende Benennung wie aus der Anlage ersichtlich vollzogen, wobei in dem Benennungsschreiben explizit hinsichtlich (...) (Anm.: = der Beklagten) darauf Bezug genommen wird, dass die Benennung sich auf solche Gegenstände beschränkt, die einen C-Chip enthalten (...). In der gelebten Vertragspraxis sei dieser einschränkende Zusatz hingegen seit dem Jahr 2009 entfallen, weshalb die Benennung nach Wahl von C auch für Drittprodukte möglich gewesen sein soll. Dies kann nicht als hinreichend sicheres Indiz für die von der Beklagten vertretene Auslegung angenommen werden. Denn es liegt vielmehr näher, dass die Vertragsparteien zum Zeitpunkt der Veränderung der Benennungspraxis im Jahre 2009 nach acht Jahren gelebter Vertragspraxis gerade selbstverständlich davon ausgegangen sind, dass auch die nachfolgenden Benennungen nur die bereits vorher gelebte Reichweite haben und ausschließlich dann den Begünstigten Schutz gewähren, wenn diese ASICs von C und nicht von Dritten bezogen haben. Zudem erscheint es nicht überzeugend, durch diese nach der Benennung von A geänderte Praxis hinsichtlich des Wortlauts der Benennungsschreiben den Schluss abzuleiten, dass auch A dann, wenn die Chips von Dritten bezogen worden sind, freigestellt werden sollte, obwohl das auf A bezogene ursprüngliche Benennungsschreiben gerade eine Einschränkung auf C ASICs enthält.

Da zwischen den Parteien unstreitig ist, dass die Beklagte auch solche Chips von Dritten bezieht, kann aus der Vereinbarung nicht die Unzulässigkeit bzw. Unbegründetheit der Klage abgeleitet werden. Denn die Klägerin greift mit der Klage auch solche Ausführungsformen an, in denen keine C-Chips verbaut wurden.

b) Damit sieht sich die Kammer im Ergebnis im Einklang mit der Sichtweise mit des *High Court*, der zwischenzeitlich in Anwendung kalifornischen Vertragsrechts in der entsprechenden Weise entschieden hat.

Die Entscheidung des *High Court* kommt in Rn. 121 ff. in Anwendung des kalifornischen Rechts und der hierin geregelten (California Civil Code, sections 1636 ff.) und durch die Judikatur anerkannten Auslegungsgrundsätze, die den gemeinsamen Willen der Parteien bei Vertragsschluss zu erkunden streben und diese Intention aus objektiven Anhaltspunkten im Vertrag oder aus außerhalb der Vertragsurkunde liegenden Umständen schließen, zu denen auch das Verhalten der Parteien nach Vertragsschluss in Bezug auf die Durchführung des Vertrages zählt (Urteil *High Court* Rn. 21 ff.), zu dem nämlichen Ergebnis, das sich bei Anwendung deutschen materiellen Rechts ergäbe.

Es könne insoweit nicht davon ausgegangen werden, dass es der Wille der vertragsschließenden Parteien gewesen sei, dass dritten Parteien im Ergebnis eine Freilizenz von der Klägerin auch dann erteilt werde, wenn hierdurch Produkte betroffen seien, in denen keine von C gelieferten Komponenten verbaut seien. Zudem spreche auch die Art und Weise, wie zwischen den Jahren 2000 und August 2008 die in der Klausel 4.3 vorgesehene Benennung praktiziert worden sei, gegen die von A vertretene Interpretation. Dieses Ergebnis erscheint der Kammer auch unter Anwendung kalifornischen Rechts zutreffend, da diese Rechtsordnung insoweit auf die nämlichen Auslegungsgrundsätze abhebt wie das deutsche Recht.

c) Die Kammer sieht davon ab, das Verfahren nach Art. 30 EuGVVO auszusetzen, bis über die Berufung gegen das nämliche Urteil des *High Court* entschieden ist. Die Beklagte hat keine Gesichtspunkte vorgebracht, auf deren Grundlage die Kammer mit hinreichender Wahrscheinlichkeit davon auszugehen hätte, dass das Urteil in der Berufungsinstanz keinen Bestand haben wird. Der Rechtsstandpunkt des *High Court* zum kalifornischen Recht erscheint der Kammer nachvollziehbar und plausibel. Bei der Auslegung ist der *High Court* unter Anwendung von Auslegungsgrundsätzen nach dem kalifornischen Recht, die den deutschen ähnlich sind, zu dem gleichen Ergebnis wie die Kammer gekommen. Vor diesem Hintergrund erachtet die Kammer die Gefahr von sich widersprechenden Entscheidungen, die Art. 30 EuGVVO im Blick hat, als gering und räumt daher dem rechtlich geschützten Interesse der Klägerin, zeitnah ein Urteil im hiesigen Verfahren zu erhalten, auch unter Berücksichtigung der Interessen der Beklagten an einer Aussetzung den Vorrang ein.

II.

1.a) Das Klagepatent referiert, dass im Stand der Technik auf eine als unzureichend erkannte Kanalqualität mit der Erhöhung der Leistung reagiert worden sei. Indes riefen hohe Sendeleistungen unerwünschte Interferenzen mit anderen Mobilfunkgeräten hervor. Diese Anpassung könne in einer offenen oder einer geschlossenen Regelungsschleife erfolgen. Hintergrund sei, dass sich die Übertragungsbedingungen im Mobilfunkbereich ständig veränderten. Ein geschlossener Leistungsregelungskreis in Uplinkrichtung, d.h. von der Mobilstation zum Netz hin, funktioniere dabei dergestalt, dass die netzwerkseitige Basisstation ein Signal von der Mobilstation empfange und dabei die Qualität des Übertragungskanals überwache. Die Basisstation gleiche sodann die gemessene Qualität des Kanals mit bestimmten Parametern ab und kommuniziere der Mobilstation mittels eines TPC-Befehls, die Sendeleistung entweder zu erhöhen oder zu verringern. Hierauf reagiere die Mobilstation und sende mit entsprechend modifizierter Leistung, die dann wiederum dieselbe Regelungsschleife durchlaufe. Dies illustriert das Klagepatent durch die Figuren 2 und 3, die den Stand der Technik grafisch darstellen.

Nachteilig sei an diesem Regelungsmechanismus, dass infolge der Erhöhung des Leistungspegels bei schlechter Kanalqualität der Energieverbrauch des Senders entsprechend steige. Zudem sei nachteilig, dass eine Erhöhung der Sendeleistung die Gefahr von Interferenzen mit sich bringe, was wiederum die Effizienz der Datenübertragung im Netz negativ beeinflusse. Im Stand der Technik sei daher auch bekannt gewesen, die Übertragung einer Mobilstation auf Betreiben des Netzwerks hin zeitweise auszusetzen, wenn sich die Kanalqualität zu sehr verschlechtere.

b) Das Klagepatent hingegen verfolgt das Ziel, unter bestimmten Bedingungen die Sendeleistung für Datensignale zu reduzieren, wenn eine weitere Erhöhung der Leistung keine verhältnismäßige Gegenmaßnahme zum Kompensieren einer abnehmenden Kanalqualität mehr ist und so die Effizienz der Datenübertragung im Netz zu verbessern.

Hierzu sieht die Lehre des Klagepatents vor, dass die Mobilstation innerhalb eines bestimmten Zeitfensters einen Datenblock sendet und mit einer Vorrichtung ausgestattet ist, die auf eine Verringerung der Kanalqualität bei Erreichen eines ersten Kriteriums mit einer Absenkung der Datensendeleistung reagiert. Wenn sich die Kanalqualität wieder verbessert und ein zweites Kriterium erfüllt wird, so erhöht die Vorrichtung die Sendeleistung wieder (vgl. Figur 4 des Klagepatents).

2. Diese Vorteile verwirkliche eine Vorrichtung nach Anspruch 1, dessen Merkmale sich wie folgt gliedern lassen:

   a Funkstation, die Folgendes umfasst:

   b Sendemittel, um über einen Kanal innerhalb einer vorgegebenen Zeitspanne einen Datenblock zu übertragen, der Informationssymbole und Paritätsprüfungssymbole enthält;

   c Steuermittel, die auf eine Angabe bezüglich einer Reduzierung der Kanalqualität gemäß einem ersten Kriterium mit einer Verringerung der Datensendeleistung reagieren;

   d Steuermittel, die auf eine Angabe innerhalb der vorgegebene Zeitspanne bezüglich einer Zunahme der Kanalqualität entsprechend einem zweiten Kriterium mit einer Erhöhung der Datensendeleistung reagieren.

III.

Die angegriffenen Ausführungsformen machen von der Lehre des Klagepatents unmittelbar wortsinngemäßen Gebrauch. Dies steht zwischen den Parteien hinsichtlich Merkmal a) außer Streit und beruht auch nicht auf patentrechtlich verfehlten Anschauungen. Die angegriffenen Ausführungsformen verwirklichen aber auch die Merkmale b, c und d.

1. Maßgeblich für die Auslegung eines Patents ist zunächst der Inhalt und damit der Wortlaut und Sinngehalt des jeweiligen Patentanspruchs, Beschreibung und Zeichnungen sind ergänzend heranzuziehen (Art. 69 Abs. 1, S. 1, 2 EPÜ). Soweit die Beschreibung zur Auslegung der Patentschrift herangezogen wird, ist der technische Sinn der in der Patentschrift verwendeten Worte und Begriffe entscheidend und nicht deren rein philologischer oder logisch-wissenschaftlicher Bedeutungsgehalt (BGHZ 150, 149, 156 – Schneidmesser I BGH GRUR 1999, 909 – Spannschraube). Die Merkmale eines Patentanspruchs müssen deshalb aus der Patentschrift, die insoweit ihr eigenes Lexikon darstellt, selbst heraus ausgelegt werden (BGH, GRUR 2005, 754 – werkstoffeinstückig). Ausführungsbeispiele sowie darauf bezogene Beschreibungsteile schränken einen weiter zu verstehenden Sinngehalt des Patentanspruchs nicht auf diese Ausführungsformen ein.

2. Bei Zugrundelegung dieser Maßstäbe sind die streitigen Merkmale durch die angegriffenen Ausführungsformen unmittelbar wortsinngemäß verwirklicht.

   a) Die Argumentation der Beklagten, ein pauschaler Verweis auf Standardspezifikationen des HSUPA-Standards sei wegen dessen Optionalität nicht ausreichend, verfängt nicht, da der geltend gemachte Vorrichtungsanspruch 1 Funkstationen

schützt, die in der Lage sind, mit ihren Sende- und Steuermitteln entsprechend der klagepatentgemäßen Lehre zu verfahren. Dies wird durch den bloßen Verweis auf die Optionalität des im UMTS-Standard seit dem Release 6 enthaltenen HSUPA-Standard nicht in Abrede gestellt.

b) Die angegriffenen Ausführungsformen machen von Merkmal b Gebrauch. Das Klagepatent lehrt, dass die Paritätsprüfungssymbole dazu dienen, fehlerhaft übertragene Daten jedenfalls zu einem gewissen Grad rekonstruieren zu können. Das ermöglichen auch die nach dem Standard vorgesehenen CRC-Bits auf dem E-DCH-Kanal, die der Fehlerprüfung dienen. Dass dann dieser Fehler auch korrigiert wird, liest der Fachmann als Selbstverständlichkeit mit. Die von der Beklagten unter Hinweis auf ein Lehrbuch, das nicht Auslegungsmaterial des Klagepatents ist, vertretene Auffassung, es sei zwischen einer Paritätsprüfung und einer zyklischen Redundanzprüfung zu unterscheiden, wobei das Klagepatent auf die Paritätsprüfung abstelle, der Standard aber nur eine zyklische Redundanzprüfung anwende, greift nicht durch. Denn Paritätsprüfungssymbole im Sinne des Klagepatents sind Informationen, die eine Korrektur von Übertragungsfehlern erlauben. Diese Funktionalität entnimmt der Fachmann Abschnitt [0037] („depending on the error correction capability of the parity check symbols"), [0039] („This truncation of the data block corresponds to puncturing the parity check symbols C and results in a reduction in the error correcting capability within the data block.") und [0041, 0052] („error capability of the parity check symbols") des Klagepatents. Diese Funktionalität erfüllen die standardgemäßen CRC-Bits auf dem E-DCH-Kanal ausweislich Anlage K C4, Ziffer 4.8.1, Seite 66 und Ziffer 4.2.1, Seite 13.

c) Die angegriffenen Ausführungsformen verwirklichen auch die Merkmale c und d.

aa) Wie die Merkmale zu verstehen sind, entnimmt der Fachmann insbesondere Figur 7 der Klagepatentschrift und der Beschreibung in Abschnitten [0031] und [0032]:

[0031] The first radio station 100 may transmit a plurality of data signals simultaneously. The power levels P_2 and P_1 may relate to the transmit power of one of the data signals or to the total combined transmit power of a plurality of the data signals. If the power levels P_2 and P_1 relate to the transmit power of one data signal, the reduction in transmit power is effected by reducing the transmit power of that data signal. If the power levels P_2 and P_1 relate to the total combined transmit power of a plurality of data signals, the reduction in transmit power may be effected by reducing the transmit power level of one or more of the data signals, for example the highest-powered data signal or signals, or by reducing the transmit power level of all of the data signals.

[0032] The first criterion may also be applied a plurality of times during the predetermined time period. For example, the first radio station 100 may transmit three data signals simultaneously, with the power levels P_2 and P_1 relating to the total combined transmit power of the three data signals. Referring to Figure 7, the first criterion is satisfied when the total combined transmit power of the three data signals reaches P_2, at time t_7 in Figure 7. At this point, the transmit power of the highest-powered of the three data signals is reduced to zero, with the result that the total combined transmit power of the data signals falls to P_1. The quality of the first channel 160 continues to deteriorate, until the combined transmit power of the two transmitted data signals reaches P_2', at time t_8 in Figure 7. At this point, the transmit power of the highest-powered of the remaining two data signals is also reduced to zero, with the result that the total combined transmit power of the data signals falls to P_1'. The quality of the first channel 160 then continues to deteriorate still further, until the transmit power of the remaining transmitted data signal reaches P_2'', at time t_9 in Figure 7. At this point, the transmit power of the third data signal is also reduced to zero, with the result that the total combined transmit power of the data signals falls to P_1'', where $P_1'' = 0$. When the quality of the first channel 160 improves, the transmit power of all the data signals may be increased at the same time when the second criterion

is considered to be met, or the second criterion may be applied a plurality of times with the power of a different data signal or plurality of data signals being increased each time the second criterion is met; in this latter case, the order in which the transmit powers of the multiple data signals are increased does not necessarily have to be the same as or the reverse of the order in which the transmit powers of the multiple data signals were reduced. In Figure 7, the transmit power of one each of the three data signals is increased at respective times t_{10}, t_{11} and t_{12}; the power levels at which the transmit power of the data signals are increased are shown to be the same as the power levels P_2, P_2', and P_2'' at which the transmit powers were decreased, but this is not essential.

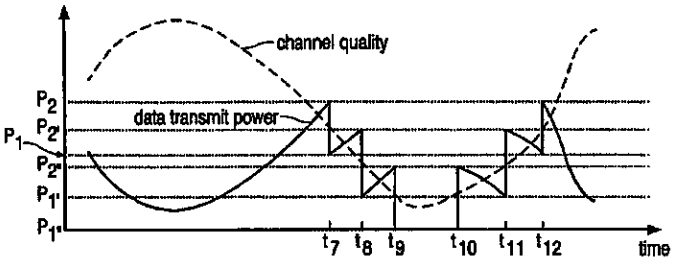

FIG.7

Der Einleitung von Abschnitt [0031] entnimmt der Fachmann, dass die Leistungsniveaus P2 und P1 sich auf die Sendeleistung eines Datensignals beziehen können oder auf die Gesamtsendeleistung einer Mehrzahl von Datensignalen. Als Hintergrund wird dem Fachmann vor Augen geführt, was er aus seinem Fachwissen ohnehin zugrunde legt, nämlich dass die beteiligten Funkstationen eine Vielzahl von Datensignalen gleichzeitig übertragen können. Die Beschreibung führt weiter aus, dass dann, wenn sich die Leistungsniveaus P2 und P1 auf die Sendeleistung eines einzelnen Datensignals beziehen, die Reduzierung der Sendeleistung dadurch bewirkt wird, dass die Sendeleistung dieses (einen) Datensignals reduziert wird. Beziehen sich die Leistungsniveaus dagegen auf eine Mehrzahl von Datensignalen, so kann die Reduzierung der Gesamtsendeleistung entweder dadurch bewirkt werden, dass die Sendeleistung aller Datensignale reduziert wird oder dadurch, dass die Sendeleistung eines oder mehrerer der angesprochenen Mehrzahl von Datensignalen reduziert wird.

Abschnitt [0032] entnimmt der Fachmann sodann in Zusammenschau mit der Figur 7 ein Beispiel, in dem die Sendeleistung dreier Datensignale in Reaktion auf sich verschlechterende Kanalqualität in drei Schritten hinsicht-

lich der Sendeleistung der drei Einzelkanäle nacheinander auf Null gesetzt und hierdurch die Gesamtsendeleistung reduziert wird. Der Fachmann erkennt dies jedoch aufgrund der Ausführungen in Abschnitt [0031] als lediglich eines von vielen möglichen Szenarien, die das Klagepatent in den Blick nimmt, ohne dessen Lehre hierauf zu beschränken. Denn Abschnitt [0031] hat er gerade entnommen, dass die Leistungsniveaus P2 und P1 sich auch nur auf die Sendeleistung eines einzelnen Datensignals beziehen können, dessen Sendeleistung dann reduziert wird.

bb) Das zuletzt angesprochene Szenario findet sich in den Standarddokumenten wieder, weshalb die Merkmale c und d verwirklicht sind. Denn es reicht aus, dass die angegriffenen Ausführungsformen auf Anforderung in der Lage sind, gemäß dem HSUPA-Standard über den TPC-Befehl, der sich jedenfalls auf die Kanäle DPDCH/DPCCH bezieht, bei Überschreitung eines gewissen Maximalwertes der Sendeleitung nach Anpassung der DPCCH-Leistung und Anwendung von Skalenfaktoren die Sendeleistung des E-DPDCH-Kanals über eine Verringerung des Stellfaktors für diesen Kanal zu reduzieren. Dass der TPC-Befehl hier nicht unmittelbar den Kanal E-DPDCH anspricht, sondern zunächst die Sendeleistung des Kanals DPCCH anpasst und dann erst die Sendeleistung des E-DPDCH über einen *gain factor*, ist patentrechtlich ohne Belang, da sich dem Klagepatent kein solches Unmittelbarkeitserfordernis entnehmen lässt. Dass wiederum in der Situation, in der nach Anpassung der DPCCH-Leistung und nach Anwendung der *gain factors* die maximale Sendeleistung überschritten würde, der *gain factor* für den E-DPDCH verringert und damit die Sendeleistung des E-DPDCH reduziert wird, obwohl der TPC-Befehl eine Verringerung der Kanalqualität angezeigt hat, ergibt sich aus dem Standard (Anlage K C6, Abschnitt 5.1.2.6, Seite 26, zweiter Absatz).

Ob dies in dem von der Beklagten in dem auf Seite 57 der Klageerwiderung (AS 226) geschilderten Szenario je nach den Umständen in einzelnen Situationen dazu führen kann, dass die Gesamtsendeleistung nicht reduziert wird, führt nach der vorstehend erläuterten Lehre, die der Fachmann dem Klagepatent entnimmt, nicht aus der Verletzung heraus, weil er erkennt, dass zur Verwirklichung der klagepatentgemäßen Lehre auch die Reduzierung auf einem Kanal ausreicht. Zwar ist der Beklagten zuzugeben, dass das klagepatentgemäße Ziel die Effizienzsteigerung und die Vermeidung von unerwünschten Interferenzen ist und dass die Erreichung dieses Ziels

durch die Reduzierung bloß der Sendeleistung eines Kanals *prima vista* schwer erreichbar scheint. Indes lässt dies der erteilte Anspruch, an den die Kammer als Verletzungsgericht gebunden ist, genügen. Dabei ist zu bedenken, dass auch die Reduzierung eines Einzelkanals jedenfalls einen Beitrag zur Erreichung des formulierten Ziels leistet. Denn wenn umgekehrt stets auf eine Gesamtsendeleistung abgestellt würde, schiene die Erreichung des Ziels schon deshalb schwer erreichbar, weil der Fachmann weiß, dass hierfür eine Vielzahl von an der Funkkommunikation beteiligten Kanälen einzustellen und anzusprechen wären und eine gleichsame zentrale Steuerung der saldierten Gesamtsendeleistung aller dieser Kanäle schwierig erschiene. Gegen eine solche Gesamtsaldierung spricht zudem, dass auch das Klagepatent dann, wenn es von einer „total combined transmit power" spricht, nur diejenige einer Mehrzahl von Kanälen anspricht, ohne zu lehren, dass hiermit stets die Gesamtheit aller an der Funkkommunikation beteiligten Kanäle gemeint ist.

IV.

Die festgestellten patentverletzenden Handlungen rechtfertigen nach Maßgabe der nationalen Bestimmungen (Art. 64 Abs. 1, Abs. 3, Art. 2 Abs. 2 EPÜ) die zu dem Klagepatente gestellten Anträge, soweit sie auf Erteilung von Auskünften und Rechnungslegung sowie die Feststellung der Schadensersatzverpflichtung gerichtet sind. Diesen Ansprüchen stehen kartellrechtliche Gesichtspunkte nicht entgegen (vgl. Huawei Technologies/ZTE: EuGH, Urteil vom 16. Juli 2015 – C-170/13, GRUR 2015, 764 Rn. 72 ff. = ECLI:EU:C:2015:477 idF des Berichtigungsbeschlusses vom 15. Dezember 2015, ECLI:EU:C:2015:817).

1. Wie beantragt war festzustellen, dass die Beklagte in dem aus dem Tenor ersichtlichen Umfang zum Schadensersatz verpflichtet ist.

   a) Die besonderen Zulässigkeitsvoraussetzungen einer Feststellungsklage nach § 256 ZPO liegen vor. Die Klägerin kennt den genauen Umfang der Benutzungs- und Verletzungshandlungen nicht. Ohne diese Kenntnis kann sie den Antrag auf Zahlung von Schadensersatz und Entschädigung nicht beziffern. Da aber die Beklagte Schadensersatzansprüche der Klägerin in Abrede stellt, hat die Klägerin – auch zur Hemmung der Verjährung und Herbeiführung der 30jährigen Verjährungsfrist – ein rechtliches Interesse daran, dass das Bestehen eines Schadensersatzanspruchs alsbald festgestellt wird.

b) Der Anspruch auf Schadensersatz ergibt sich aus § 139 Abs. 2 PatG. Die Beklagte hat schuldhaft, nämlich zumindest fahrlässig gehandelt. Es gilt der Grundsatz, dass der Patentbenutzer bei Anwendung der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt spätestens einen Monat nach Veröffentlichung der Mitteilung über die Erteilung des Klagepatents hätte erkennen können und erkennen müssen, dass das Klagepatent durch die angegriffenen Ausführungsformen verletzt wird. Diese Karenzzeit spielt vorliegend keine Bedeutung, da die Beklagte nach Ablauf dieser Frist gegründet wurde.

c) Eine zeitliche Beschränkung der Schadensersatzfeststellung auf einen Monat nach ihrer Eintragung in das Handelsregister war entgegen der Ansicht der Beklagten nicht vorzunehmen. Insbesondere war der Beklagten keine Karenzzeit von einem Monat nach ihrer Gründung und erst Recht nicht nach ihrer Handelsregistereintragung einzuräumen, bevor sie zumindest der Fahrlässigkeitsvorwurf hinsichtlich der Patentverletzung trifft. Vielmehr wären ihre Geschäftsführer gehalten gewesen, vor der Geschäftsaufnahme die Schutzrechtslage zu prüfen. Insoweit ist die Konstellation nicht mit derjenigen vergleichbar, in der Produkte im laufenden Geschäftsbetrieb verkauft werden und währenddessen ein entgegenstehendes Patent erteilt wird. In einer solchen Situation ist es angebracht, dem Patentbenutzer eine Frist von einem Monat zuzugestehen, da ihm nicht zugemutet werden kann, im laufenden Geschäftsbetrieb tagtäglich zu prüfen, ob für eines der laufenden Produkte zwischenzeitlich ein entgegenstehendes Patent erteilt wurde. Demgegenüber stellt jedoch die Geschäftsaufnahme wie überhaupt jede neue Produkteinführung ein singuläres Ereignis dar, vor dem dem Patentbenutzer zugemutet werden kann, die Schutzrechtslage zu prüfen. Tut er dies nicht oder unterliegt er bei der Beurteilung der Schutzrechtslage einem Irrtum, trifft ihn grundsätzlich der Fahrlässigkeitsvorwurf. Gesichtspunkte, weshalb vorliegend ausnahmsweise etwas anderes gelten sollte, sind weder vorgetragen noch sonst ersichtlich.

Dementsprechend war die Feststellung der Schadensersatzpflicht ohne zeitliche Einschränkung auszusprechen.

2. Die Beklagte ist der Klägerin aufgrund der vorliegenden Verletzung der Klagepatente zur Auskunft und Rechnungslegung verpflichtet. Die Klägerin kann den Schadensersatzanspruch nicht ohne Kenntnis der Umstände, über die sie Auskunft fordert, berechnen. Da diese Umstände der Klägerin als Betriebsinterna der Beklagten naturgemäß unbekannt sind, die Beklagte hierüber aber anhand ihrer Buchhaltung ohne unzumutbaren Arbeitsaufwand Auskunft geben kann, ist die Beklagte gem. § 140 b PatG

und einer zu Gewohnheitsrecht erstarkten Anwendung von § 242 BGB zur Auskunft verpflichtet. Entsprechend der zeitlichen Reichweite der potentiellen Haftung beginnt die Auskunftspflicht bereits mit der Gründung der Beklagten, nicht erst mit ihrer Eintragung in das Handelsregister. Diese Auskunft hat sich auch auf den Gewinn der Beklagten und die zu seiner Berechnung erforderlichen Daten zu beziehen. Die Klägerin muss durch die Auskunft erst in die Lage versetzt werden, sich für eine der möglichen Berechnungsarten ihres Schadensersatzanspruchs (Verletzergewinn, entgangener Gewinn oder fiktive Lizenz) zu entscheiden.

Die Klage war auch nicht deshalb hinsichtlich der Rechnungslegung teilweise abzuweisen, weil die Klägerin in ihren Antrag keinen Vorbehalt dahingehend aufgenommen hat, dass der Beklagten nachgelassen wird, geheimhaltungsbedürftige Informationen außerhalb der auskunftspflichtigen Informationen zu schwärzen. Zwar trifft es zu, dass der Beklagten aus Verhältnismäßigkeitsgründen grundsätzlich ein entsprechendes Schwärzungsrecht zusteht. Allerdings handelt es sich hierbei um die Art und Weise der Erfüllung des Rechnungslegungsanspruches. Die Frage der Erfüllung ist erst in einem etwaigen Vollstreckungsverfahren relevant. Nur wenn die Klägerin zum Gegenstand ihres Antrags macht, dass ihr ungeschwärzte Kopien vorzulegen sind, muss eine entsprechende Teilklageabweisung erfolgen. Verhält sich die Klägerin demgegenüber in ihren Anträgen und dem zu ihrer Auslegung heranzuziehenden Sachvortrag nicht dazu, ob sie geschwärzte oder ungeschwärzte Kopien erhalten möchte, lässt sie diesen Punkt gerade offen, so dass es keiner Entscheidung im Erkenntnisverfahren bedarf. An diesem Befund ändert sich auch nichts, wenn die Beklagte ausdrücklich auf ihr Recht, Kopien entsprechend schwärzen zu dürfen hinweist, und den Antrag deshalb für in diesem Punkt unbegründet hält, die Klägerin indes gleichwohl keine Antragsanpassung oder sonstige Klarstellung vornimmt. Hieraus kann nämlich nicht geschlossen werden, dass die Klägerin die Vorlage von ungeschwärzten Kopien fordern würde.

3. Die unter Ziffern 1 und 2 erörterten Ansprüche sind auch nicht in ihrem Umfang aufgrund kartellrechtlicher Einwendungen zu beschränken. Die Klägerin ist entgegen der Auffassung der Beklagten nicht auf die Berechnung des Schadensersatzes in Höhe einer FRAND-Lizenz beschränkt. Der Europäische Gerichtshof hat klargestellt, dass die Durchsetzung von vergangenheitsbezogenen Schadensersatzansprüchen und hierauf bezogenen Auskunfts- und Rechnungslegungsansprüchen nicht dem kartellrechtlichen Einwand unterliegt. Die abweichende Auffassung des Oberlandesgerichts Düsseldorf (vgl. etwa Vfg. im Verfahren I-2 U 32/16 vom 15. Juni 2016 teilt die Kammer aus diesem Grund nicht.

4. Die vorgenannten Ansprüche sind auch nicht teilweise verjährt. Infolge der Verhandlungen zwischen A und der Klägerin war die Verjährung der Ansprüche gehemmt. Dies betraf auch die Ansprüche gegen die Beklagte als deutsche Tochtergesellschaft, da Verhandlungsgegenstand nicht allein Ansprüche gegen die Muttergesellschaft, sondern auch gegen deren nationalen Tochtergesellschaften wie etwa die Beklagte waren, da es um Verhandlungen über eine weltweite Portfolio-Lizenz ging, in deren Genuss nach den üblichen Gepflogenheiten sämtliche Konzerngesellschaften von A gekommen wären. Jedenfalls nach den Grundsätzen der Anscheins- bzw. Duldungsvollmacht verfügte A über eine entsprechende Verhandlungsvollmacht der Beklagten. Dass die Verhandlungen zu irgendeinem Zeitpunkt abgebrochen worden wären, indem A sowohl Patentverletzungen als auch die Bereitschaft weiter zu verhandeln verneint hätte, hat die insoweit darlegungs- und beweisbelastete Beklagte nicht vorgetragen und ist auch sonst nicht ersichtlich.

V.

Hingegen war die Klage abzuweisen, soweit die Klägerin überdies von der Beklagten Unterlassung, Rückruf und Entfernung aus den Vertriebswegen sowie die Vernichtung patentverletzender Produkte begehrt. Denn insoweit stehen einer gerichtlichen Durchsetzung der Ansprüche in Anwendung der Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs in der Rechtssache Huawei ./. ZTE (EuGH, Urteil vom 16. Juli 2015 – C-170/13, GRUR 2015, 764 = ECLI:EU:C:2015:477 idF des Berichtigungsbeschlusses vom 15. Dezember 2015, ECLI:EU:C:2015:817) kartellrechtliche Gründe entgegen.

1. Das Klagepatent, das die HSUPA-Technologie betrifft, vermittelt der Klägerin auf der Grundlage des relevanten Sach- und Streitstands eine marktbeherrschende Stellung, sodass sie Normadressatin der kartellrechtlichen Vorschriften ist. Die Klägerin hat bereits in der Klageschrift hervorgehoben, dass das HSUPA-Schema eine Ausbaustufe des UMTS-Standards sei. Soweit sie die marktbeherrschende Stellung erstmals wenige Tage vor der mündlichen Verhandlung, in Abrede gestellt hat, war dieser Vortrag nach § 296 Abs. 2 ZPO verspätet. Diese Auffassung vertrat die Klägerin erstmals ausdrücklich im Schriftsatz vom 17. Oktober 2016, per Fax vorab an diesem Tag um 19 Uhr eingegangen, und verwies darin auf angeblichen Vortrag in der Replik (vgl. Fn. 15 AS 401), der an der zitierten Stelle und auch sonst ein solcher Vortrag nicht zu entnehmen ist. In der Klageschrift führte die Klägerin unter III.1., Seite 84 aE in einem Satz darauf, dass das HSUPA-Kommunikationsprotokoll nicht erforderlich sei, um UMTS-Mobiltelefone zu vermarkten, da man auch ohne den schnellen Uplink-Datenkanal auskommen könne, argu-

mentierte in der Replik dann aber ausführlich dazu, dass das D-Angebot FRAND sei und kartellrechtlichen Vorgaben standhalte (AS 292-323).

Da die Klägerin nach den in der Klageerwiderung enthaltenen Ausführungen der Beklagten zu ihren aus der marktbeherrschenden Stellung der Klägerin abgeleiteten kartellrechtlichen Einwendungen ausführlich vorgetragen hat, hätte die Klägerin eine solche Stellung bereits in der Replik substantiiert in Abrede stellen können und müssen, sodass die Verspätung auf grober Nachlässigkeit beruht. Soweit die Klägerin an anderer Stelle im Zusammenhang mit der Vorstellung der Lehre des Klagepatents, mit der Verletzungsdiskussion anhand des UMTS-Standards und mit der Benennung der angegriffenen Ausführungsformen darauf verwiesen hat, dass UMTS-fähige Mobiltelefone und Tablets auch ohne das HSUPA-Protokoll vermarktet werden könnten, sind diese Ausführungen unzureichend. Die Ausführungen haben keinen Bezug zu der Frage, ob der Klägerin durch das Klagepatent eine marktbeherrschende Stellung zukommt. Insbesondere hat die Klägerin in diesem Zusammenhang eine marktbeherrschende Stellung nicht in Abrede gestellt. Nach Auffassung der Kammer hat die Klägerin in den genannten Passagen lediglich den UMTS-Standard zu seiner Ausbaustufe mit dem HSUPA-Protokoll abgegrenzt und in diesem Zusammenhang darauf verwiesen, dass Mobilstationen auch ohne HSUPA UMTS-fähig sind und insoweit als UMTS-fähige Geräte verkauft werden könnten. Ein Bestreiten der marktbeherrschenden Stellung kann die Kammer den Ausführungen nicht entnehmen. Ein Bezug der Ausführungen zum kartellrechtlich relevanten Markt ist nicht ersichtlich. Insbesondere behauptet die Klägerin in den genannten Passagen nicht, dass der Markt sämtlicher UMTS-fähigen Mobilstationen (und nicht ein Markt, der nur Multimediageräte wie Smartphones und Tablets umfasst, bei denen es auf eine schnelle Internetverbindung ankommt) der relevante Produktmarkt sei und es dem potentiellen Käufer gleichgültig sei, ob das Gerät etwa auch dann, wenn nur UMTS zur Verfügung steht, über schnelle Datenverbindungen auf dem Uplink-Kanal verfügt. Soweit die Klägerin in ihrer Replik ebenfalls darauf abhebt, dass ein UMTS-fähiges Gerät auch ohne HSUPA vermarktet werden könne, gilt nichts anderes. Es handelt sich zudem um Ausführungen dazu, ob das Klagepatent im Sinne des Vertrags zwischen der Klägerin und C ein technisch zwingendes Patent für den CDMA-Standard ist, nicht aber wird die Vermittlung einer marktbeherrschenden Stellung an sich in Abrede gestellt. Die Klägerin argumentiert gerade zu der Kartellrechtsfrage nach der Rechtsprechung des EuGH, ohne auf den Punkt der marktbeherrschenden Stellung einzugehen und diesen in Abrede zu stellen. Die Kammer ist nicht in der Lage, die Frage der marktbeherrschenden Stellung aus eigener Sachkunde zu beurteilen, weshalb bei Berücksichtigung des verspäteten Vortrags ein das Verfahren verzögerndes Sachverständigengutachten einzuholen wäre.

2. Die Kammer hat ihr Verständnis des Urteils des Gerichtshofs der Europäischen Union in der Sache Huawei / ZTE im Urteil vom 29. Januar 2016 - 7 O 66/15 (veröffentlicht bei juris) dargelegt und hält nach nochmaliger Überprüfung der dort vertretenen Rechtsauffassung an dieser Begründung fest.

Aus Sicht der Kammer betont der Gerichtshof, dass das aus einem Patent fließende Ausschließlichkeitsrecht nur unter ganz besonderen Umständen nicht mit der Verletzungsklage durchsetzbar ist. Daraus folgt, dass die entsprechenden tatsächlichen Umstände, aus denen sich die Suspendierung des Patentrechts ergeben soll, von dem in Anspruch genommenen (angeblichen) Verletzer vorzutragen und wenn die Umstände im Streit stehen, auch zu beweisen sind.

Der Gerichtshof entwickelt aus Sicht der Kammer in seinem Urteil ein Konzept, dass es dem zur Entscheidung berufenen Gericht ermöglichen soll, das Verhalten des Inhabers des SEP auf der einen Seite sowie des angeblichen Verletzers auf der anderen Seite daraufhin zu bewerten, ob sich die Durchsetzung der auf das SEP gestützten Unterlassungs- und Rückrufanträge als ungerechtfertigter Marktmissbrauch und Aufbau eines insoweit zu unterbindenden Drucks in der Verhandlungssituation zu bewerten ist oder als gerechtfertigte Reaktion auf eine vom (angeblichen) Verletzer verfolgte Verzögerungstaktik. Hingegen zielt die Entscheidung des Gerichtshofs nach der Überzeugung der Kammer nicht darauf ab, die Verletzungsgerichte mit der Bestimmung der FRAND-Bedingungen zu belasten, wenn im Verfahren der Unterlassungs- und Rückrufanspruch durchgesetzt werden soll und es nicht gerade um die Zahlung einer FRAND-Lizenzgebühr im Betragsverfahren geht. Dass der Gerichtshof diesen Gesichtspunkt, den der Generalanwalt in seinen Schlussanträgen angesprochen hat, in seiner Urteilsbegründung nicht ausdrücklich erwähnt, bedeutet nach Ansicht der Kammer entgegen den Darlegungen des Oberlandesgerichts Karlsruhe (Beschl. v. 31.5.2016 - 6 U 55/16, MittdtschPatAnw 2016, 321) nicht, dass das vom Gerichtshof für Recht erkannte System nicht praxisgerecht sein soll.

Zu diesem Zweck hält es der Gerichtshof für erforderlich, dass der Patentinhaber in einem ersten Schritt vor der Erhebung einer auf Rückruf und Unterlassung gerichteten Klage, die für den angeblichen Verletzer einen erheblichen Verhandlungsdruck aufbaut, einen angeblichen Verletzer auf die ihm vorgeworfene Patentverletzung hinweist und dabei das SEP bezeichnet sowie angibt, auf welche Weise es verletzt sein soll. Jedenfalls wird der Patentinhaber das mit der Klage geltend gemachte und von ihm als standardessentiell deklarierte Patent mit seiner Patentnummer bezeichnen und angeben müssen, dass dieses Patent bei der betreffenden Standardisierungsorganisation als

standardessentiell deklariert wurde. Soweit der Patentinhaber zudem angeben soll, auf welche Weise das Patent verletzt sein soll, muss der Hinweis dem Verletzer deutlich machen, für welchen Standard das Patent essentiell ist und aufgrund welcher Umstände der Patentinhaber davon ausgeht, dass der angebliche Patentverletzer von der Lehre des Patents Gebrauch macht. Jedenfalls ist dafür erforderlich, dass der Patentinhaber benennt, welche technische Funktionalität der angegriffenen Ausführungsform vom Standard Gebrauch macht. Der angebliche Verletzer wird regelmäßig nämlich im Bilde darüber sein, dass sein Produkt einem Standard gemäß ausgebildet ist. Daher dürfte ein bloßer Hinweis, der angebliche Verletzer stelle nach dem Standard arbeitende Produkte her oder vertreibe diese und verletze deshalb das Patent, nicht ausreichend sein. Vielmehr muss der angebliche Verletzer durch den Hinweis in die Situation versetzt werden, die Schutzrechtslage selbständig prüfen (lassen) zu können. Aufgrund der Vielzahl der technischen Funktionalitäten, die regelmäßig in einem Standard enthalten sind und die gerade die vom Gerichtshof angesprochene Unübersichtlichkeit bei der Beurteilung der Schutzrechtslage begründet, wird es erforderlich sein, dass der SEP-Inhaber jedenfalls die Kategorie der technischen Funktionalität des Standards in einer solchen Weise benennt, dass der vermeintliche Verletzer nun wieder der grundsätzlich ihm obliegenden Pflicht, die Schutzrechtslage zur prüfen, gerecht werden kann. Wie detailliert dieser Hinweis zu erfolgen hat, kann nur nach den jeweiligen Umständen des Einzelfalls entschieden werden. Hierbei wird insbesondere einzustellen sein, welche Technologiekenntnisse beim Patentverletzer vorhanden sind bzw. inwieweit er sich solche Kenntnisse in zumutbarer Weise durch professionellen Rat zu verschaffen hat. Aus Sicht der Kammer sind zur Darlegung des Verletzungssachverhalts in einer den Anforderungen des Gerichtshofs entsprechenden Weise grundsätzlich jedenfalls die auch im Rahmen von Lizenzvertragsverhandlungen nach den geschäftlichen Gepflogenheiten sonst üblichen Claim-Charts ausreichend, die den geltend gemachten oder einen ihm verwandten Anspruch des Klagepatents, der gleichfalls die entscheidenden Merkmale aufweist, gegliedert nach Anspruchsmerkmalen den entsprechenden Stellen im Standard gegenüberstellen, ohne dass hierbei die Anforderungen der Schlüssigkeitsprüfung einer Verletzungsklage erfüllt werden müssen. Insoweit ist in der Regel ausreichend, dass der angebliche Verletzer den vom SEP-Inhaber erhobenen Vorwurf jedenfalls bei Hinzuziehung externen oder internen technischen Sachverstandes nachvollziehen kann.

Entsprechendes gilt für die weitere Obliegenheit des SEP-Inhabers, der zudem vor Klageerhebung dem angeblichen Patentverletzer – sofern dieser im Grundsatz seinen Willen zum Ausdruck gebracht hat, überhaupt Lizenz nehmen zu wollen – ein konkretes schriftliches Lizenzangebot zu FRAND-Bedingungen zu unterbreiten hat und insbesondere die Lizenzgebühr und die Art und Weise ihrer Berechnung anzugeben hat. Vor

dem Hintergrund des zuvor geschilderten Verständnisses, das die Kammer zu der Entscheidung des Gerichtshofs entwickelt hat, ist hierfür erforderlich, dass es sich um ein annahmefähiges Vertragsangebot handelt, das die vertragswesentlichen Bedingungen enthält. Soweit der Gerichtshof ausführt, dass der Patentinhaber ein konkretes schriftliches Lizenz-Angebot zu FRAND-Bedingungen unterbreiten hat, bedeutet dies nicht, dass das Verletzungsgericht für den Fall, dass der (angebliche) Patentverletzer – wie regelmäßig – in Abrede stellt, dass dieses Angebot FRAND-Kriterien entspricht, gehalten ist, nunmehr nach objektiven Gesichtspunkten zu entscheiden, ob das Angebot des SEP-Inhabers tatsächlich FRAND ist oder nicht. Denn hierdurch würde der Verletzungsprozess gerade wieder mit der Bestimmung belastet, welche Lizenzhöhe exakt und sonstigen Vertragsbedingungen ganz genau diesen Kriterien entsprechen, was aus Sicht der Kammer nicht das Anliegen des Gerichtshofs war. Kartellrechtswidrig und ersichtlich nicht FRAND ist ein Angebot erst dann, wenn es sich unter Berücksichtigung der konkreten Verhandlungssituation und insbesondere der Marktgegebenheit als Ausdruck von Ausbeutungsmissbrauch darstellt. Dies bedeutet freilich nicht, dass der Patentinhaber sich mit der bloßen Behauptung begnügen dürfte, sei Forderung sei fair, vernünftig und nicht diskriminierend.

Der Patentinhaber hat dabei vielmehr die Art und Weise der Berechnung der Lizenzgebühr so anzugeben, dass hierin deutlich wird, aus welchen darzulegenden Gründen er von einer Erfüllung der FRAND-Kriterien ausgeht. Nach Auffassung der Kammer wird der SEP-Inhaber den angeblichen Verletzer in die Lage versetzen müssen, anhand objektiver Kriterien nachzuvollziehen, warum der SEP-Inhaber zu der Überzeugung gelangt, dass das von ihm unterbreitete Angebot FRAND-Kriterien entspricht. Hierfür ist nicht ausreichend, dass der SEP-Inhaber bei einem Stücklizenzvertrag schlicht den pro Einheit zu zahlenden Betrag angibt, ohne zu erläutern, weshalb dieser Betrag nach seiner Ansicht FRAND-Bedingungen entspricht. Insoweit wird er den Betrag gegenüber dem vermeintlichen Verletzer in geeigneter Weise transparent zu machen haben, etwa durch Vortrag zu einem in der Vertragspraxis gelebten und von Dritten akzeptierten Standardlizenzprogramm oder unter Heranziehung anderer Bezugsgrößen, aus dem die geforderte Lizenzgebühr abgeleitet wird, wie etwa aus einer Poollizenzgebühr, die in der Praxis für einen Patentpool von Dritten gezahlt wird, der auch für den fraglichen Standard relevante Patente umfasst.

Der Verletzer muss auf dieses, auf konkret darzulegenden Tatsachen fußende Angebot reagieren, selbst wenn es seiner Auffassung – wie regelmäßig – nicht den FRAND-Kriterien entspricht (ebenso im Ergebnis LG Mannheim, Urteil vom 27.11.2015 - 2 O 106/14 Seite 51 bei (bb) und LG Düsseldorf, Urteil vom 3. November 2015 - 4a O

144/14). Eine Ausnahme hiervon ist nach der Auffassung der Kammer allein in solchen Fällen zu machen, in denen sich das Angebot des SEP-Inhabers bereits bei summarischer Prüfung evident als nicht FRAND und mithin als Missbrauch einer beherrschenden Stellung des SEP-Inhabers darstellt. Dieses Gegenangebot ist alsbald zu unterbreiten, da der Gerichtshof dem angeblichen Patentverletzer keine Verzögerungstaktik zugestehen will. Mithin muss vom angeblichen Verletzter auf das konkrete schriftliche Angebot des SEP-Inhabers so schnell reagiert werden, wie dies nach den Umständen des Einzelfalls bei Anwendung der in dem Bereich anerkannten geschäftlichen Gepflogenheiten und des Grundsatzes von Treu und Glauben von ihm erwartet werden kann.

Schlägt der SEP-Inhaber dieses Angebot aus und hat der angebliche Verletzer das SEP bereits benutzt, bevor ein Lizenzvertrag geschlossen wurde, verlangt der Gerichtshof, dass er ab dem Zeitpunkt der Ablehnung des Gegenangebots eine angemessene Sicherheit etwa durch Beibringung einer Bankgarantie oder durch Hinterlegung leistet. Die Berechnung der Sicherheit muss unter anderem die Zahl der vergangenen Benutzungshandlungen in Bezug auf das SEP umfassen, für die der angebliche Verletzer eine Abrechnung vorlegen können muss. Diese Sicherheit muss zudem den in dem betreffenden Bereich anerkannten Gepflogenheiten entsprechen.

3. Bei Zugrundelegung dieser Maßstäbe ist die Klägerin vorliegend aus kartellrechtlichen Gründen gehindert, die mit der Klage verfolgten Ansprüche durchzusetzen.

   a) Ob diese Maßstäbe der Kammer vor dem Hintergrund des Beschlusses des Oberlandesgerichts Karlsruhe vom 31. Mai 2016, Az.: 6 U 55/15, der meint, dass eine Evidenzkontrolle des Angebots des SEP-Inhabers einerseits nicht ausreichend sei, andererseits aber ausführt, dem SEP-Inhaber sei bei der Beurteilung, was FRAND sei, ein Entscheidungsspielraum zuzugestehen, und der lediglich eine summarische Prüfung im Rahmen eines Antrags auf einstweilige Einstellung der Zwangsvollstreckung aus einem erstinstanzlichen Urteil betrifft, im Detail einer Überprüfung unterzogen werden müssen, kann vorliegend offen bleiben.

   b) Denn die Klägerin hat vorliegend ihre Obliegenheit nicht erfüllt, gegenüber der Beklagten transparent zu machen, aufgrund welcher Tatsachen sie den von ihr im Lizenzvertragsangebot geforderten Lizenzsatz von US$ (...) pro Stück für FRAND hält - bzw. warum dieser in der Diktion des Oberlandesgerichts Karlsruhe im Rahmen des zuzugestehenden Entscheidungsspielraums FRAND ist. Sie hat sich vielmehr darauf beschränkt, in ihrem Angebot pauschal zu behaupten, dass die angemessene Lizenz US$ (...) bzw. (...) US$ pro Stück sei. Insoweit ist nach Auffassung der Kammer die bloße Angabe der Multiplikatoren nicht annähernd aus-

reichend, um die Vorgaben der Entscheidung des Gerichtshofs zu erfüllen. Auch der pauschale Verweis auf weitere Lizenznehmer ohne nähere Erläuterung der Lizenzbedingungen sowie der gleichfalls pauschale Verweis auf das Portfolio von Samsung sowie ein nicht zugänglich gemachtes Sachverständigengutachten aus dem E-Verfahren haben die Beklagte nicht in die Lage versetzt, valide zu prüfen, ob das Angebot der Klägerin FRAND ist und nicht hinreichend plausibel gemacht, warum die Klägerin meint, der Auffassung sein zu dürfen, die von ihr geforderten Konditionen entsprächen FRAND. Der Verweis auf einen nicht bezeichneten „Hauptakteur der Telekommunikations-Branche", die angeblichen Erkenntnisse der Firma K sowie die angebliche Stärke des Portfolios ist insoweit nicht ausreichend. Die Klägerin hat vielmehr noch im Oktober 2015 die Auffassung vertreten, insoweit die Art und Weise der Berechnung nicht näher erläutern zu müssen.

Von der Obliegenheit zur Erläuterung der Art und Weise der Berechnung der Lizenzgebühr war die Klägerin im konkreten Fall auch nicht etwa deshalb befreit, weil A – argumentationshalber unterstellt – selbst über umfangreiche Erfahrungen und Marktkenntnisse verfügte, wie die Klägerin behauptet, und daher in der Lage war, im November 2015 eigene Vorstellungen zu einer angemessenen Lizenzhöhe zu entwickeln und wohl auch in den Verhandlungen argumentativ zu begründen. Nach Auffassung der Kammer hat die Obliegenheit zur Erläuterung der Art und Weise der Berechnung der Lizenzgebühr nicht allein den Zweck, den Patentbenutzer dazu in die Lage zu versetzen einzuschätzen, ob das Angebot tatsächlich FRAND ist, und ggf. ein Gegenangebot zu formulieren, so dass die Obliegenheit entfallen könnte, wenn der Patentbenutzer selbst über umfangreiche Marktkenntnis verfügt. Vielmehr bezweckt die Obliegenheit nach Auffassung der Kammer auch, dass die Parteien miteinander ins Gespräch kommen und konstruktiv über die Frage der Lizenzhöhe diskutieren können. Wie regelmäßig werden die Parteien nämlich bei der Frage, welcher Lizenzsatz FRAND ist, auseinanderliegen und zwar unabhängig von der Expertise, über die der Patentbenutzer verfügt. Auch wenn der Patentbenutzer über Marktkenntnisse verfügen sollte, ist es für eine Einigung förderlich, wenn der Patentinhaber nicht nur ein Angebot machen muss, sondern auch die Art und Weise der Berechnung konkret zu erläutern hat. Hierdurch wird nämlich transparent, in welchen Eingangsgrößen für die Bestimmung der Lizenzgebühr die Parteien in ihrer Beurteilung auseinanderliegen. Erkannte Beurteilungsdifferenzen können leichter einer Einigung zugeführt werden, als wenn Unsicherheit darüber besteht, auf welche Weise die Lizenzgebühr konkret ermittelt wurde. Schon aus diesem Grund ist es gerechtfertigt, dem Patentinhaber zuzumuten, dass er die Art und Weise der Berechnung im Einzelnen

substantiiert darlegt. Durch diese Transparenz werden überdies etwaige Unsicherheiten auf Seiten des Patentbenutzer über die konkrete Art und Weise der Berechnung durch den Patentinhaber beseitigt. Schließlich kann es auch Situationen geben, in denen der Patentbenutzer, obwohl er über hinreichende Expertise verfügt, bei seinen eigenen Berechnungen einem Irrtum unterliegt, den er nur bemerkt, wenn der Patentinhaber ihm seine Herleitung im Einzelnen darlegt. Auch aus diesem Grund ist es für Lizenzverhandlungen und zur Vermeidung unnötiger gerichtlicher Auseinandersetzungen, die der Gerichtshof nach Auffassung der Kammer gerade vermeiden möchte, förderlich, wenn der Patentinhaber gehalten ist, die Art und Weise der Berechnung der Lizenzgebühr auch dann im Einzelnen transparent zu machen und zu begründen, warum er diese für FRAND hält, wenn der Patentbenutzer ein Weltkonzern ist, der ebenfalls Erfahrung auf dem Gebiet von Lizenzverträgen hat. Dies gilt jedenfalls dann, wenn der Patentbenutzer zu einem abweichenden Ergebnis hinsichtlich einer FRAND-Lizenzgebühr gelangt. Hinzu kommt im konkreten Fall, dass die Beklagte die Kläger unstreitig sogar zu einer weiteren Erläuterung aufgefordert und damit zu erkennen gegeben hat, dass sie sich auf der bisherigen Grundlage nicht als zureichend informiert ansieht.

c) Soweit die Klägerin entsprechende Erläuterungen erstmals in der Replik gemacht hat, sind diese nach Klageerhebung erfolgt und damit nicht mehr geeignet, die vom Europäischen Gerichtshof verfolgte Intention zu erfüllen, die Verhandlungen unbelastet von der Erhebung einer auf Unterlassung, Rückruf, Entfernung und Vernichtung gerichteten Klage führen zu können. Insoweit sind die Ausführungen des Europäischen Gerichtshofs nach Auffassung der Kammer vor dem Hintergrund der Intention, die der Gerichtshof mit seinem Pflichtenprogramm verfolgt, zu verstehen, dass nicht nur vor Klageerhebung auf die Art und Weise der vorgeworfenen Patentverletzung hingewiesen werden soll. Sondern dieses zeitliche Erfordernis bezieht sich gleichfalls auf die Angabe, auf welche Art und Weise sich die Lizenzgebühr im Angebot des SEP-Inhabers berechnet, also aufgrund welcher Tatsachen die konkret geforderte Gegenleistung für die Lizenzierung fair, vernünftig und nicht diskriminierend sei soll. Denn nur wenn auch die Art und Weise der Berechnung der Lizenzgebühr vor Klageerhebung substantiiert wurde, kann sich der angebliche Verletzer, ohne dem Druck einer bereits erhobenen Unterlassungsklage ausgesetzt zu sein, im Verhandlungswege entscheiden, ob er gewillt ist, die so transparent gemachten Bedingungen als FRAND entsprechend anzuerkennen und Lizenz zu nehmen. Soweit in einem Beschluss des Oberlandesgerichts Düsseldorf vom 9. Mai 2016 (Az.: I - 15 U 36/16) das Gericht erwägt, ob es in allen Fällen erforderlich ist, dass die vom Gerichtshof aufgestellten Obliegenhei-

ten, hier insbesondere die Verpflichtung zur Erläuterung der Gebührenberechnung, vor Klageerhebung zu erfüllen sind und ob dies gegebenenfalls als zu formaljuristisches Verständnis der Entscheidung abzulehnen ist, hält die Kammer an ihrer bisherigen Rechtsprechung fest. Denn selbst wenn es prozessual möglich sein sollte, dass die Klägerin, die ihre Obliegenheiten bislang nicht vor Klageerhebung erfüllt hat, dies nachholt, die zunächst erhobene Klage zurücknimmt und dann unter Beachtung der Obliegenheiten erneut erhebt, ist zu sehen, dass in diesem Fall in der Zeit zwischen der Rücknahme der zunächst erhobenen Klage und erneuter Erhebung der Klage Zeit für Verhandlungen bleibt, in denen die Verhandlungen ohne den unmittelbaren Druck eines gerichtlichen Verfahrens geführt werden können. Denn selbst wenn der SEP-Inhaber entsprechend im ersten Verfahren die zunächst unterlassene Erläuterung nachholt, so wird er dem vermeintlichen Verletzer vor erneuter Klageerhebung eine gewisse Zeit zuzugestehen haben, in der der Beklagte die Argumente prüft, die der SEP-Inhaber zur Untermauerung der Art und Weise der Berechnung der Lizenzhöhe sowie der Frage, ob die angesonnene Lizenzgebühr FRAND entspricht, vorgebracht hat. Würde man es uneingeschränkt zulassen, dass der SEP-Inhaber seine vorprozessual nicht erfüllten Obliegenheiten im Verlauf des Verfahrens sanktionslos nachholen kann, so würde nach Ansicht der Kammer der Leitgedanke der Entscheidung des Gerichtshof, Verhandlungen unbelastet von einem anhängigen Verfahren führen zu können und zu diesem Zeitpunkt über alle Informationen zu verfügen, die eine Beurteilung zulassen, ob das angesonnene Lizenzvertragsangebot FRAND-konform ist oder nicht, verfehlt. Die Kammer sieht sich in dieser Auffassung dadurch bestärkt, dass der Gerichtshof insoweit durch Berichtigungsbeschluss klargestellt hat, dass sich die Worte „vor Klageerhebung" sowohl auf die Erläuterung zur Patentverletzung als auch auf die Erläuterung der geforderten Lizenzgebühr beziehen.

d) Die Klägerin war auch vorliegend nicht etwa von dieser Obliegenheit entbunden, weil sich die Beklagte als lizenzunwillig gezeigt hätte. Die Beklagte hat über mehrere Jahre in einer Vielzahl von Treffen mit der Klägerin über einen möglichen Lizenzvertrag verhandelt und hierfür erhebliche Ressourcen aufgewendet. Sie hat nicht etwa die Lizenznahme von vornherein abgelehnt, sondern noch vor Klageerhebung mitgeteilt, welche Lizenzbedingungen sie für akzeptabel halten würde. Selbst wenn die Vorstellungen der Parteien hier erheblich voneinander abweichen, dokumentiert dieser Gegenentwurf eine grundsätzliche Lizenzwilligkeit und kann nicht als bloßes Scheinangebot gewertet werden. Zudem ist aus Sicht der Kammer zu berücksichtigen, dass die Beklagte bzw. deren Muttergesellschaft – wenngleich erst nach Klageerhebung, nämlich am 18. Februar 2016 – einen namhaften

Betrag iHv € (...) hinterlegt hat. Zwar liegen diese Umstände nach Klageerhebung, indes wertet die Kammer dieses Verhalten als Indiz auch für die grundsätzliche Lizenzwilligkeit der Beklagten bzw. der Muttergesellschaft jedenfalls in einem solchen Maße, dass die nähere Erläuterung der kaufmännischen Bedingungen, hier insbesondere der Höhe der verlangten Lizenzgebühr nicht obsolet gewesen wäre.

Das Gesamtverhalten der Beklagten bzw. ihrer Muttergesellschaft lassen nicht den Schluss zu, es handele sich um einen von vornherein lizenzunwilligen Verhandlungspartner, dem gegenüber keine Verpflichtung besteht darzulegen, aus welchen tatsächlichen Gründen die angesonnenen Angebote FRAND entsprechen.

VI.

Schließlich ist auch keine Aussetzung des Verletzungsrechtsstreits mit Blick auf die von der B erhobene Nichtigkeitsklage geboten.

Insoweit hat die Beklagte keinerlei eigenen Vortrag gehalten, aus welchen Gründen die Nichtigkeitsklage erfolgreich sein soll, sondern pauschal auf die als Anlage vorgelegte Nichtigkeitsklage verwiesen. Dies genügt nach ständiger Kammerrechtsprechung nicht der Darlegungslast desjenigen, der unter Hinweis auf den mangelnden Rechtsbestand eine Aussetzung des Verletzungsverfahrens begehrt. Dass die Beklagte sich vorliegend an einem entsprechenden Vortrag durch Klausel 4.3 der Vereinbarung zwischen D und C gehindert sieht, rechtfertigt keine andere Bewertung. Die insoweit zu treffende Beurteilung der prozessualen Risiken hat die Beklagte zu tragen und sich vorliegend entschieden, der Kammer als nichtfachmännisch besetztem Kollegium nicht darzulegen, aus welchen Gründen die Nichtigkeitsklage zum Bundespatentgericht überwiegend wahrscheinlich zur Vernichtung des Klagepatents führen soll

VII.

Die Nebenentscheidungen folgen aus §§ 92 S. 1, 709 S. 1 und 2 ZPO.

(...)	(...)	(...)
Vorsitzender Richter am Landgericht	Richter am Landgericht	Richter am Landgericht

Verkündet am 24.02.2017

(...), JSekr´in (b)
Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle